

身分犯の共犯に関して、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの()内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑤までの()内にはそれぞれ異なる語句が入る。

【会話】

学生A. 業務者でも財物の占有者でもない甲が、財物を業務上占有する乙を教唆して当該財物を横領させたという事例について考えてみましょう。

私は、刑法第65条との関係では真正身分犯と不真正身分犯との区別は重要でなく、同条第1項が違法身分の連帯的作用を、同条第2項が責任身分の個別的作用を定めたという見解に立ち、占有者を違法身分、業務者を責任身分と解するので、甲には(①)の教唆犯が成立すると考えます。

学生B. Aさんの見解には、(②)との批判がありますね。

私は、甲に業務上横領罪の教唆犯が成立し、単純横領罪の刑を科すべきと考えます。

私は、まず(③)という考え方に立ち、業務上横領罪について(④)と考えて刑法第65条第1項を適用します。その上で、単純横領罪の刑を科すのは(⑤)と考えるからです。

【語句群】

- a. 業務上横領罪 b. 単純横領罪 c. 刑法第65条の文言に反する
d. 刑法第65条第2項は成立罪名まで個別化する規定である
e. 成立する罪名と科刑の分離を回避すべきだ
f. 業務者ではない占有者が業務上横領に加功した場合との刑の均衡を図るべきだ
g. 刑法第65条第1項が真正身分犯について身分の連帯的作用を、同条第2項が不真正身分犯について身分の個別的作用を定めた規定である
h. 不真正身分犯 i. 真正身分犯

1. ①a ②d ③g ④h ⑤e
2. ①a ②f ③e ④i ⑤d
3. ①b ②c ③f ④h ⑤e
4. ①b ②c ③g ④i ⑤f
5. ①b ②e ③d ④h ⑤f

(参照条文) 刑法

第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

№175	身分犯の共犯	正答率
R5-14	正解	87%

() には順に、「① = b、② = c、③ = g、④ = i、⑤ = f」と入り、したがって、正解は肢 4 となる。

①、②について

65 条 1 項と 2 項の関係については解釈上争いがある。この点、学生 A は、65 条との関係では真正身分犯と不真正身分犯との区別は重要でなく、同条 1 項が違法身分の連帯的作用を、同条 2 項が責任身分の個別的作用を定めたという見解に立っていると言及している。この見解は、違法評価の連帯性、責任評価の個別性という犯罪論の一般原則と結びつけて、65 条 1 項と 2 項の関係を説明するものである。この見解に立った場合には、本問事案との関係でいうと、特に、業務上横領罪 (253 条) における業務者という身分が違法身分なのか、責任身分なのかを巡って解釈が分かれているが、学生 A は、占有者を違法身分、業務者を責任身分と解する立場に立つと言及しているので、単純横領罪 (252 条) の他人の物の占有者という地位は連帯的に作用し、業務上横領罪 (253 条) の業務者という地位は個別的に作用する結果、業務者でも財物の占有者でもない甲が、財物を業務上占有する乙を教唆して当該財物を横領させた本問事例においては、甲に単純横領罪 (252 条) の教唆犯 (61 条) の教唆犯が成立することとなる。したがって、①には「b. 単純横領罪」が入る。

このような学生 A が主張する見解に対しては、65 条 1 項は、「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為」と規定し、2 項は、「身分によって特に刑の軽重があるとき」としているにすぎず、この文言からこれらをそれぞれ違法身分と責任身分に関する規定であると読むことは無理があるとする批判がある。したがって、②には「c. 刑法第 65 条の文言に反する」が入る。

③、④、⑤について

これに対して、学生 B は本問事例において、「甲に業務上横領罪の教唆犯が成立し、単純横領罪の刑を科すべき」としている。本問語句群において、65 条 1 項と 2 項の関係に関する解釈を展開しているのは、g の語句であるが、この見解によった場合に、甲に業務上横領罪 (253 条) の教唆犯 (61 条) が成立するためには、業務上横領罪も真正身分犯であると考え必要がある。したがって、③には「g. 刑法第 65 条第 1 項が真正身分犯について身分の連帯的作用を、同条第 2 項が不真正身分犯について身分の個別的作用を定めた規定である」が入り、④には「i. 真正身分犯」が入る。

そして、学生 B は結論として、甲に業務上横領罪 (253 条) の教唆犯 (61 条) が成立するが、単純横領罪 (252 条) の刑を科すべきとしているが、これは、単なる占有者が業務上横領行為に関与した場合の均衡が考慮されているから考えられている。すなわち、単なる占有者には 65 条 2 項の適用が認められて単純横領罪の共犯が成立するのに対して、非占有者が業務上横領罪に関与した場合、この者に 65 条 1 項の適用が認められて業務上横領罪 (253 条) の共犯が成立するだけだとすると、単なる占有者と非占有者の間で刑の不均衡が生じるからである。なお、最判昭 32.11.19 (百選 I 94 事件) は、結論において学生 B と同じ立場を採っている。したがって、⑤には「f. 業務者ではない占有者が業務上横領に加功した場合との刑の均衡を図るべきだ」が入る。